

1500102-23.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... se prove o contrário.

Cálculo da Pena - Tráfico de Entorpecentes - Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido - Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500102-23.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500102-23.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIVELTON VILLAS BOAS CAETANO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

ERIVELTON VILLAS BOAS CAETANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na inicial, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária de São Vicente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 36 porções de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica.

O réu foi notificado e ofereceu defesa preliminar. Recebida a denúncia, foi o réu citado.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, ao

final, foi o réu interrogado.

Realizados os debates, o Ministério Público pediu a procedência da ação para a condenação do réu, nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes do acusado, bem como o reconhecimento das circunstâncias agravantes relativa à calamidade pública e à reincidência, pedindo, por fim, a aplicação da causa de aumento de pena descrita na denúncia. Requereu, outrossim, a fixação do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pedindo o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública, o aumento de pena em seu mínimo legal quanto à circunstância agravante relativa à reincidência, bem como o afastamento da causa de aumento de pena descrita na exordial.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelo laudo pericial, bem como pelo conjunto probatório constante dos autos.

Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime descrito na denúncia.

Disse que sua residência situa-se em Boituva e, ao retornar de viagem para a unidade prisional, foi usar o banheiro. Contou que o local possuía boxes e quando saiu de um deles e lavaria suas mãos, foi abordado. Alegou que a droga estava no banheiro, e não em sua posse. Contou que o banheiro é público e havia outras pessoas usando-o. Não soube por que motivo os agentes penitenciários o acusaram de estar portando as drogas. Não conhecia as demais pessoas que estavam usando o banheiro. Alegou que após ser abordado, os agentes penitenciários mandaram que as demais pessoas saíssem do banheiro, e ficaram somente consigo no local.

Contudo, a negativa do réu e a versão por ele fornecida não encontram respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos.

A testemunha agente penitenciário Wesley de Souza Covre, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que, no retorno de saída temporária, prendeu o réu em flagrante portando drogas, tentando entrar na unidade prisional. Disse que estava acompanhado do agente penitenciário Alessandro, realizando ronda externa quando verificaram uma movimentação anormal de pessoas na parte do estacionamento do estabelecimento prisional. Declarou que, ao averiguarem o que estaria ocorrendo, viram o acusado no banheiro que se encontra no estacionamento, portando uma sacola praticamente cheia, contendo quantidade significativa de maconha, em porções prontas para consumo. Consignou que o banheiro onde o réu foi detido está localizado dentro da unidade prisional, na subportaria, sendo o primeiro acesso à unidade anteriormente à revista, e esclareceu que se referiu à ronda como sendo externa por ser fora da área dos pavilhões. Relatou que a ronda era realizada em um ponto para organização dos sentenciados que retornavam da saída temporária e a movimentação atípica que visualizou tratava-se de pessoas que estavam na fila e dela saíram para entrar no banheiro. Narrou que as demais pessoas que entraram no banheiro já haviam dele saído quando lá ingressou e surpreendeu o réu segurando a sacola, com os dois braços, à altura da barriga. Asseverou que, ao deter o réu, não havia mais ninguém com ele. Declarou que o réu não forneceu esclarecimentos sobre os fatos, apenas admitindo a autoria do crime de imediato.

No mesmo sentido, a testemunha agente penitenciário Alessandro Scarpel Alves, ouvida em Juízo, narrou que realizava ronda com o agente penitenciário Wesley durante o retorno de saída de detentos, em um setor onde há um banheiro destinado a visitas. Declarou que ingressou no banheiro e flagrou o acusado segurando as drogas. Relatou que, questionado, o acusado alegou possuir uma dívida, sem esclarecer com quem, e disse que, para pagá-la, iria engolir os entorpecentes para ingressar na unidade prisional. Consignou que o réu foi detido no banheiro localizado no estacionamento, em área que antecedia a revista pessoal, em um espaço destinado a visitas para ingresso pela subportaria, mas esclareceu que o local já estava em área de segurança da unidade prisional. Declarou que, além do réu, que

estava portando a droga, havia um preso distante dele usando o banheiro. Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminoso do acusado, no que se refere ao tráfico de drogas, diante das provas produzidas. Ressalta-se a palavra dos agentes penitenciários, que de maneira segura, uniforme e convincente, descreveram com detalhes como ocorreu a abordagem do acusado e a apreensão da droga.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos dos agentes de segurança.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal). Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2ª T.- HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Mm. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.

2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).

3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842).

4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.

5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP - Rel. Min. Luiz Fux - j. 25.02.14 - DJU 18.03.14; HC 118.380/SP - Rel. Min. Teori Zavaski - j. 04.02.14 - DJU 14.02.14; HC 116.541/ES - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 21.05.2013 - DJE 06.06.13; HC 109.236/SP - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 13.12.11 - DJU 14.23.12).

Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.

6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira;

Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

“Tráfico de entorpecentes – Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes – Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor – Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino – Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva – Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva.” (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a):

Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

Apenas para consignar, o esforço da Defesa em desqualificar os depoimentos das testemunhas agentes penitenciários não é suficiente para retirar a força probante deles.

Frise-se que os depoimentos dos agentes penitenciários colhidos durante a instrução criminal mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a abordagem do réu e a localização dos entorpecentes com ele, além de estarem em verdadeira consonância com suas declarações prestadas à Autoridade Policial.

Ambas as testemunhas afirmaram ter visto o acusado dentro do banheiro, segurando uma sacola onde constatarem, após a abordagem, haver drogas.

Em que pese ter a testemunha Wesley relatado uma movimentação atípica de pessoas,

que teriam saído da fila e entrado no banheiro, asseverou o depoente que, ao ingressar no banheiro, somente o réu lá estava, segurando a sacola com entorpecentes.

Nesse mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Alessandro que afirmou ter visto o acusado portando as drogas e acrescentou ter ele admitido que iria engolir os entorpecentes para ingressar na unidade prisional, dizendo que assim agiria para poder pagar uma dívida. A versão confirma o intuito do réu de ingressar na unidade prisional, engolindo as porções de drogas que estavam na sacola que carregava, conforme restou consignado nos depoimentos colhidos em solo policial.

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, não há dúvidas de que era o acusado que estava portando as drogas, bem como não há qualquer dúvida de que o réu era o indivíduo que estava realizando o tráfico de drogas no local dos fatos e que a ele pertenciam os entorpecentes apreendidos.

De outro lado, nenhuma testemunha arrolada exclusivamente pela Defesa foi trazida em Juízo para ser ouvida, a fim de esclarecer os fatos ou, ao menos, contrariar concretamente a versão apresentada pelas testemunhas agentes penitenciários.

Assim, a negativa do réu e a versão por ele apresentada não se mostraram críveis e restaram absolutamente isoladas do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a versão fornecida pelo acusado sobreponha-se aos depoimentos dos agentes de segurança encarregados de sua prisão, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem o delito.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos dos agentes penitenciários, pois são absolutamente aptos e suficientes para embasarem a inequívoca conclusão de que o réu é de fato traficante.

No presente caso os elementos de convicção são contundentes, seja em virtude da quantidade das drogas apreendidas, seja pela ação da equipe de segurança penitenciária, tudo aliado à negativa isolada do réu.

Apenas para consignar, não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do acusado deriva da quantidade de drogas e demais circunstâncias em que o entorpecente foi apreendido. De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - AC 1.327/92 - Rel. Adolphino A. Ribeiro - RDTJRJ 20/310).

Finalmente, restou comprovada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos, uma vez que o acusado foi preso em flagrante nas dependências do Centro de Progressão Provisória desta cidade, quando pretendia adentrar com a droga na unidade prisional.

Ressalte-se que ambas as testemunhas agentes penitenciários asseveraram que o local onde o acusado foi detido estava situado já nas dependências do estabelecimento prisional, na área de segurança para o ingresso pela subportaria. Não se tratava, portanto, de área externa à unidade prisional, mas apenas externa à área dos pavilhões.

Observe-se que há disposição expressa no inciso III de aumento da pena prevista no artigo 33 quanto "a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais", pouco importando, para seu reconhecimento, portanto, ter o acusado conseguido seu intento de efetivamente ingressar nos pavilhões.

Provadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a condenação do réu é medida que se impõe.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,

verifico que o acusado é portador de maus antecedentes, conforme certidão criminal de fls. 45/46. Assim, aumento a pena-base do acusado em 1/6, ficando ela fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o réu é reincidente pela prática de mesma espécie de delito, conforme certidão criminal de fls. 46/47, motivo pelo qual aumento sua pena em 1/3, a qual resta fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor já estabelecido.

O Código de Processo Penal, embora não mais cuide detalhadamente do instituto da reincidência específica, contém ainda dispositivos que diferenciam os institutos da reincidência genérica e da específica, dando a esta última tratamento mais severo. São exemplos o artigo 44, §3º e o artigo 83, V.

Nesse sentido já entendeu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/3 NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A reprimenda imposta ao paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e variedade das drogas. Precedentes. 3. Possibilidade de agravamento da pena em 1/3, na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica. 4. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HABEAS CORPUS HC 305029 SP 2014/0244748-0 (STJ). 5ª T. Rel. Min. GURGEL DE FARIA. Julg. 25/11/2014. Public. 03/12/2014 - grifei)

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS EM OUTRO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - No caso concreto, o tema da suposta violação de domicílio, em face do v. acórdão de origem n. 1501792-47.2019.8.26.0066, já foi tratado no processo conexo, o HC n. 680.167/SP, julgado em 16/11/2021, por esta Quinta Turma, verbis: "No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residuiu no fato de que havia denúncia pormenorizada, a qual apontou o local da traficância, a descrição e o nome do acusado, bem como onde seria o esconderijo das drogas.

Soma-se a isso a fuga do paciente, ao verificar a simples presença dos policiais em frente da residência. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, após confissão informal do paciente, somada aos petrechos encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal".

III - Na dosimetria, quanto à pena-base e à segunda fase, trata-se de outro tema também antes enfrentado por esta Corte na impetração conexa, nas seguintes linhas: "Por entender desfavorável a natureza e a quantidade da droga apreendida (68,5g de crack e 33,5g de maconha), o d. Juiz a quo elevou, fundamentadamente, a pena-base. Enquanto condição preponderante nesta fase, não se afigura a desproporcionalidade. (...) Ademais, na segunda fase da dosimetria, houve exasperação da pena provisória em virtude da reincidência específica (certidão condenatória no processo nº 0001236-61.2015 - fl. 95), o que se mostra plenamente possível. Precedentes".

IV - Diante desse cenário, sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, quando configurada a mera reiteração de

pedidos, confira-se: "Constatado que o presente recurso ordinário é mera reiteração de outro recurso ordinário interposto anteriormente perante esta Corte, com identidade de causas de pedir e de pedidos, não há como dar curso à irresignação" (AgRg no RHC n. 106.171/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 1º/3/2019). Habeas corpus não conhecido." (HC 716.268/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022 - grifei)

Verifico, ainda, que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em 1/6, ficando a pena fixada em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa, no valor já estabelecido.

Na terceira fase da dosimetria da pena, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, aumento a pena em 1/6, totalizando em 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 1057 (mil e cinquenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal.

Não se pode reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da reincidência específica do acusado.

Com efeito, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização dos maus antecedentes ou reincidência para o aumento da pena nas primeiras fases da dosimetria e, ainda, suas considerações para fins de afastamento da redutora prevista na Lei de Drogas, posto que tal conjuntura, na primeira e segunda em relação à terceira etapa de dosagem das penas, possui natureza jurídica diversa.

Neste sentido, já decidiu o Pretório Excelso, confira-se:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA/MAUS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO. IDONEIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante considerou os maus antecedentes ostentados pelo réu e a natureza altamente nociva da droga apreendida, de modo que a reprimenda não merece nenhum reparo nesse ponto. II Não procede a alegação de que a inexistência de certidão cartorária atestando o trânsito em julgado de eventual condenação inviabilizaria o reconhecimento de maus antecedentes/reincidência e que a folha de antecedentes criminais não serviria para esse fim. Esta Corte já firmou entendimento no sentido da idoneidade do referido documento, que possui fé pública. Precedentes. III Infração cometida em transporte público. Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006. IV Não caracteriza bis in idem a consideração da reincidência para fins de majoração da pena-base e como fundamento para a negativa de concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. V- Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosas. VI Réu que apresenta maus antecedentes, condição que impede a aplicação da referida causa de diminuição. VII - Ordem denegada. (HC 107274, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 12/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 19-04-2011 PUBLIC 25-04-2011 LEXSTF



v. 33, n. 388, 2011, p. 367-376).

Ainda no mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. "1. Constatando-se que a paciente ostenta maus antecedentes, ausente ilegalidade na não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista o não preenchimento de exigência determinada nesta regra. "2. As circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante da agente, somadas à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendida em seu poder - mais de 3 quilos de maconha -, ademais, levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, dedicando-se a atividade criminosa..." (STJ HC 230.835/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 21/09/2012).

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, cuidando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cujo aspecto altamente nocivo à sociedade em geral ninguém desconhece, por certo que não se afigura socialmente adequada e recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, além de ser o réu reincidente específico, motivos pelos quais fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Não estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa por liberdade por restritiva de direitos. Também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ERIVELTON VILLAS BOAS CAETANO, qualificado nos autos, às penas de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1057 (mil e cinquenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se os malefícios inerentes ao

tráfico de drogas ao meio social, além de ser o acusado reincidente. A reiteração de condutas criminosas evidencia a dificuldade do réu em aceitar a ordem legal estabelecida, pois não hesita em reiterar a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição. Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 30 de março de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA